

0000060-47.2018.8.26.0323

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...)
6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator:
Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...)
Condição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000060-47.2018.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000060-47.2018.8.26.0323

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 265/2017 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL DE CASTRO TERRA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de GABRIEL DE CASTRO TERRA, qualificado nos autos, na qual lhe é atribuída a prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em razão dos fatos narrados na exordial acusatória, às fls. 66/67.

Oferecida a denúncia, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 101/102). Não sendo caso de absolvição, a denúncia foi recebida em 28/10/2020. Na mesma decisão, o Juízo designou audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 104). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu. Após, as partes apresentaram suas alegações finais, por escrito.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 147/150).

A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a

desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, ou, se condenado nos termos da exordial, que a pena fosse aplicada em seu mínimo patamar; que a redutora inerente ao tráfico privilegiado fosse reconhecida; que fosse estabelecido o regime diverso do mais gravoso; o recurso em liberdade e; por fim, que o réu fosse agraciado com a justiça gratuita (fls. 154/160).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 12), laudos de constatação provisória (fls. 24/26) e definitivo (fls. 127/129), detectada a presença da substância "cocaína", que se encontra descrita na Lista F1 (Lista das Substâncias Entorpecentes) da Lista F (Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017 de 10/07/2017); bem como pelas provas orais.

De igual modo, a autoria é certa, recaindo sobre os ombros do acusado. Senão vejamos.

O policial militar Gustavo José dos Santos Ferreira contou que estava em patrulhamento de rotina por local alvo de denúncias anônimas anteriores envolvendo o tráfico de drogas, quando avistou o réu sentado. Disse que o acusado, ao vê-lo, tentou deixar o local, porém, foi contido e abordado. Esclareceu que na posse de Gabriel foi encontrado cinco pinos plásticos contendo 'cocaína', além de R\$ 80,00 (oitenta reais). Já no local onde este encontrava-se sentado, outros quinze pinos do mesmo entorpecente foram achados. Dada suspeita do imóvel onde o acusado estava sentado em frente, e após o seu morador, de nome Wesley, consentir com a sua entrada, o depoente passou a vistoria-lo, vindo a encontrar mais dinheiro e outros quatro pinos de "cocaína" em seu interior. Por fim, disse que até aquele dia não conhecia o réu.

Seu companheiro de farda, Danilo Rodrigues de Souza, fez eco às suas declarações. Acrescentou ainda que os pinos plásticos contendo "cocaína" encontrados com o acusado era idênticos aos encontrados no local onde estava sentando no momento da aparição policial na cena.

Já a testemunha Wesley Guatura Barbosa de Oliveira Geraldo afirmou não conhecer o réu.

Por sua vez, o réu negou os fatos durante sua autodefesa. Disse que na data dos fatos havia saído da casa de sua namorada e comprado entorpecentes para seu consumo próprio, no momento que os agentes da lei o abordaram, enquanto aguardava o troco do traficante. Afirmou que não conhecia os policiais militares que o prenderam. Contou que havia dado uma nota de cem reais por cinco pinos de "cocaína" e que o vendedor havia saído para buscar o troco em local que desconhece. Negou a responsabilidade pelas outras quinze porções do entorpecente encontradas pela polícia no local onde estava.

Esse, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, é fato incontroverso nos autos que o acusado possuía, ao menos cinco pinos de "cocaína" e dinheiro, no momento em que foi abordado por policiais militares.

O ponto nodal do processo, portanto, é desvendar o destino que Gabriel daria aos entorpecentes: se os venderia ou os consumiria.

Ante as circunstâncias do caso concreto, entendo que o réu possuía as drogas para fins de tráfico, conforme passarei a expor.

Primeiramente, há que ter em mente a situação flagrada pelos policiais militares ao chegarem à cena criminoso, frise-se, local conhecido pela venda de entorpecentes: o réu encontrava-se sentado e sozinho (na posse das drogas e dinheiro).

Insta registrar, como já sustentado em outras oportunidades, que aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costume conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

Frise-se: nem os policiais militares conheciam Gabriel até o dia dos fatos, não o réu os conhecia.

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decurso o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tal diretriz, entendo que o caso, ora em apreço, é mais um daqueles em que o réu tenta em vão desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova da sua alegação, procurando atenuar sua responsabilidade, assumindo conduta menos gravosa (artigo 28, da Lei 11.343/06).

Ora, como se vê, em sede policial e, ao contrário dos policiais militares envolvidos nessa ocorrência que mantiveram a mesma narrativa ao longo de toda perseguição criminal, Gabriel apresentou enredo diverso daquele trazido em Juízo.

Com efeito, na fase administrativa, o acusado disse que estava no local para adquirir drogas, mas, devido a súbita ação policial, viu-se impedido de concretizar seu intento, com a fuga dos traficantes que ali operavam. Ou seja, naquela ocasião, Gabriel negou que estivesse na posse de quaisquer drogas (p. 08).

Porém, como já visto alhures, sob o crivo do contraditório, o acusado inovou, dizendo que, na verdade, já havia adquirido as cinco porções encontradas em seu poder pelos agentes públicos e, que estava no local esperando receber o troco da compra efetuada pelo traficante.

Tal mudança de postura, evidentemente, é sintomática.

Outro ponto a fortalecer a versão acusatória, é o fato de o réu possuir entorpecentes e dinheiro, em quantias consideráveis, algo incomum nesses casos.

A experiência forense demonstra que o usuário, devido à vontade incontrollável do vício, utiliza todo o dinheiro que possui no momento da transação para comprar as drogas que consome. Inclusive, um dos motivos para essas substâncias serem proibidas é exatamente a dependência que elas causam, a ponto de levar o usuário e, na maioria da vezes, a sua família à falência financeira.

Logo, a circunstância de Gabriel ter sido flagrado na posse de valores não deixa de ser mais um a indicativo da mercancia.

Pelo que se depreende, a ação exteriorizada pelo acusado é típica daquele que é conhecido no meio do narcotráfico por "vapor", que nada mais do que o indivíduo, na cadeia criminosa, responsável pela venda diretamente aos usuários nas ruas da cidade.

Por estar mais exposto à ação da polícia, tais indivíduos procuram esconder a maior parte da droga sob responsabilidade deles em local próximo àquele onde costumam vendê-las, de modo proposital, justamente para dificultar a caracterização do narcotráfico, caso sejam surpreendidos em situação típica, permanecendo com tão somente pouco quantidades em suas posses diretas.

Não por acaso, aliás, foram encontrados mais quinze pinos de "cocaína" no local onde Gabriel foi visto inicialmente pelos policiais, idênticos em cor e tamanho àqueles encontrados em seu poder.

Não se está aqui afastando a possibilidade do increpado ser, eventualmente, usuário de drogas, fato que sequer foi comprovado pela defesa: o que se afirma é que tal circunstância não exclui a tipicidade de sua conduta delitiva no tráfico. Afinal, não é incompatível com o fato de também ser traficante.

Como é de notório conhecimento, não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência ou enriquecer e, nos presentes autos, somadas as informações trazidas pelos agentes da lei, do local e o comportamento do acusado, foi apreendida quantidade considerável para um único viciado e, como já dito, dinheiro, não se podendo falar em desclassificação para delito diverso, mais leve.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

"Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado

parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Destarte, à luz das provas orais e das circunstâncias acima apontadas, tenho que as drogas localizadas tinham como destino o vil comércio.

Esclareço, outrossim, ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como quantidade das drogas e dinheiro.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

O caso, portanto, é de condenação, nos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

O réu é tecnicamente primário, vez que a condenação sofrida em feito distinto pela prática do mesmo crime destes autos, ainda não transitou em julgado (autos nº 1500555-93.2018.8.26.0621, em trâmite nesta Vara Criminal, consulta realizada no SAJ, nesta data).

Logo, não será utilizada para valorar a conduta do acusado, conforme Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

Súmula 444 : "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Anote-se, ainda, que a quantidade de droga (20,08 gramas, peso líquido, de cocaína, divididos em 20 pinos plásticos), não excede ao normal já previsto nesse tipo penal, observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei 11.343/06.

Assim, estabeleço a basilar no piso legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado, conforme artigo 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, deixo de atenuar a sanção, pois já estabelecida no piso legal, em respeito a jurisprudência sumulada do STJ:

Súmula 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Não existem agravantes.

Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas na etapa final, torno definitiva a pena de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Registre-se que o réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vez que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda

intimidade com o narcotráfico à época, evidenciando sua dedicação àquelas atividades criminosas, a despeito de sua condição de primário e de bons antecedentes, aos olhos da lei.

A uma, por não ter comprovado a realização de ofício legítimo.

A duas, por já ter sido condenado em primeiro e segundo graus de jurisdição pelo mesmo delito, ora em voga, nos autos nº 1500555-93.2018.8.26.0621, cuja certidão atualizada, ora determino a juntada nestes autos.

A propósito, informativo desse mesmo Tribunal Superior, nesse sentido:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; STJ; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

Anoto que todos esses elementos indicam claramente que o indigitado é pessoa que se dedica às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o

impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Destarte, dado que essa causa de redução da pena é destinada àquele que age por um impulso, em situação isolada no tráfico de drogas, incidindo na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado se cuidou apenas de um desvio na vida do acusado, não é o caso destes autos.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, devido ao C. Supremo Tribunal Federal – STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que isso não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando as circunstâncias judiciais acima mencionadas, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GABRIEL DE CASTRO TERRA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado; bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diária mínima, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

O montante de pena aplicado não permite a aplicação de medidas despenalizadoras.

Concedo ao réu, no entanto, o apelo em liberdade, por ter respondido a todo o processo nessa condição, não existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua custódia preventiva, mesmo agora após sua condenação.

Custas na forma da lei.

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia apreendida com o réu, à fl. 12, em favor da União, ante as evidências de ser originária do vil comércio, conforme acima exaustivamente fundamentado, com fulcro no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Expeça-se o necessário, com o trânsito em julgado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Preliminar – Restituição de valor apreendido – Desacolhimento – Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas – Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido – Perda em favor da união corretamente determinada – Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 – Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) – Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Por outro lado, com relação ao celular e o dinheiro apreendidos no interior da casa diligenciada (fls. 13), nada fora produzido nos autos indicando o emprego do aparelho no crime destes autos, ou mesmo de que eram produtos do mesmo. Assim, intime-se a quem de direito para retirá-lo e levá-lo, apresentando prova idônea de sua propriedade, com relação ao aparelho celular. Não sendo tal aparelho reclamado e/ou aquela quantia levantada, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverá ser vendido em leilão, depositando-se o saldo, e/ou transferindo ao juízo de ausentes. Caso o aparelho celular não apresente mais conteúdo econômico, após a devida certificação nos autos, fica autorizada sua destruição, observada as disposições normativas pertinentes.

Atente-se a serventia para a regularização dos autos, vez que ainda permanecem na classe de inquérito policial.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão e, com a captura do acusado, a guia de execução; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA